

刑法
No.72

共通問題 H29-7

(配点：2)

月	日
月	日

次の【記述】中の①から④までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

被害者の同意が問題となる場合としては、一般に以下のような分類がなされている。第1は、被害者の意思に反することが構成要件要素になっている場合であり、この類型においては、被害者の同意は構成要件該当性を阻却する。窃盗罪は、この類型に①(a. 入る・b. 入らない)。第2は、被害者の同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない場合である。13歳未満の者に対するわいせつ行為は、この類型に②(c. 入る・d. 入らない)。第3は、被害者の同意がある場合とない場合が分けて規定され、被害者の同意があると軽い方の罪が成立する場合である。業務上墮胎罪は、この類型に③(e. 入る・f. 入らない)。第4は、被害者の同意が行為の違法性を阻却する場合である。住居侵入罪の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと解した場合、同罪は、この類型に④(g. 入る・h. 入らない)。

1. ①a ②c ③e ④h
2. ①a ②c ③f ④h
3. ①a ②d ③f ④g
4. ①b ②c ③e ④h
5. ①b ②d ③f ④g

No.72

被害者の同意

正答率

共通H29-7

正解

38%

() には、順に「①a ②c ③e ④h」が入り、したがって、正解は肢1となる。

①について

窃盗罪（235条）における「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させ、取得する行為であるから、窃盗罪は、被害者の意思に反することが構成要件要素となっているものである。そのため、占有者の同意のある占有取得は「窃取」に当たらず、窃盗罪の構成要件に該当しない。よって、窃盗罪は、被害者の意思に反することが構成要件要素になっている類型に入る。したがって、①には「a. 入る」が入る。

②について

不同意わいせつ罪（176条3項）は、13歳未満の者を被害者とする場合には、同意があっても犯罪が成立する。よって、不同意わいせつ罪は、被害者の同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない類型に入る。したがって、②には「c. 入る」が入る。

③について ★

業務上墮胎罪（214条前段）は、医師等の業務者の身分に基づく同意墮胎罪（213条前段）の加重類型であるところ、不同意墮胎罪（215条）との関係では、215条1項の法定刑が6月以上7年以下の拘禁刑であるのに対し、214条前段の法定刑が3月以上5年以下の拘禁刑であることから、法定刑は業務上墮胎罪の方が軽い。よって、医師等の業務者による墮胎の場合には、被害者の同意があると業務上墮胎罪が成立するため、被害者の同意があると軽い方の罪が成立する類型に入る。したがって、③には「e. 入る」が入る。

④について

住居侵入罪（130条前段）の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと解する住居権説による場合、住居権者の同意があると、「侵入」に当たらず、構成要件に該当しない。よって、被害者の同意が行為の違法性を阻却する類型には入らないことになる。したがって、④には「h. 入らない」が入る。